

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1843/2563

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
นาย อ.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 279 วรรคห้า (ใหม่), มาตรา 283 ทวิ
วรรคสอง, มาตรา 317 วรรคสาม
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

ความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม มุ่งคุ้มครองอำนาจปกครองดูแล
ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มิให้ถูกผู้ใดล่วงละเมิดได้ ข้อสาระสำคัญจึงอยู่ที่ว่าขณะ
มีการกระทำความผิด เด็กนั้นอยู่ในความปกครองดูแลของผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ หาก
ปรากฏว่าเด็กอยู่ในอำนาจปกครองดูแลไม่ว่าเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว ผู้ใดก็
ไม่อาจมารบกวนหรือทำให้อำนาจปกครองของบุคคลนั้นต้องถูกกระทบกระเทือนโดย
ปราศจากความรู้เห็นยินยอมของบุคคลดังกล่าวได้

ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 อายุ 6 ปีเศษ อยู่ในอำนาจปกครองดูแลของ ห.
เพียงแต่เดินผ่านหน้าบ้านของจำเลยจะไปตาม ต. กลับมารับประทานอาหารที่บ้าน
เหตุที่แหวะไปหาจำเลยเพราะจำเลยเรียกผู้เสียหายที่ 1 ให้เข้าไปหาที่แคร่หน้าบ้าน
จำเลยแล้วล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายที่ 1 จึงถือได้ว่าเป็นการพรากเด็กออกจาก
อำนาจปกครองที่มีอยู่เหนือผู้เสียหายที่ 1 เป็นเหตุให้อำนาจปกครองถูกกระทบ
กระเทือนแล้ว แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายที่ 1 อยู่ในความปกครองดูแลของผู้
เสียหายที่ 2 มิใช่ ห. ตามที่พิจารณาได้ความก็ตาม ข้อแตกต่างดังกล่าวก็ไม่ถือเป็น

ข้อสำคัญอันกระทบต่อสาระอันเป็นเนื้อหาขององค์ประกอบความผิด ศาลขอจะ
ลงโทษจำเลยไปตามข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได้ความดังกล่าวนี้ได้ตาม ป.วิ.อ.
มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277,
279, 283 ทวิ, 284, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคสาม, 279 วรรคหนึ่ง, 283 ทวิ วรรคสอง, 284 วรรคหนึ่ง, 317 วรรคสาม
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร
โดยใช้อุบายหลอกลวง ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร ฐาน
กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และ
ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้น
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 7 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี
ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร รวม 2 กระทง จำคุก
กระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 24 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) และมาตรา 317 ความผิดฐาน กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อ การอนาจาร และฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ให้ลงโทษ ฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกกระหนละ 2 ปี รวม 2 กระหน เป็นจำคุก 4 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งโจทก์และจำเลยโต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังยุติ ได้ว่า เด็กหญิง ก. ผู้เสียหายที่ 1 ขณะเกิดเหตุอายุ 6 ปีเศษ เป็นบุตรของนาย ร. กับ นาง ส. ครั้งเมื่อบิดาและมารดาของผู้เสียหายที่ 1 แยกทางกัน ผู้เสียหายที่ 1 จึงมา พักอาศัยและอยู่ในความปกครองดูแลของนาง ห. ผู้เป็นยายส่วนนาง ว. ผู้เสียหายที่ 2 ย่าของผู้เสียหายที่ 1 อยู่คนละหมู่บ้านกับนาง ห. ในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง ขณะผู้เสียหายที่ 1 เดินผ่านบ้านจำเลยซึ่งอยู่ใกล้กันจำเลยเรียกผู้เสียหายที่ 1 ให้มา นั่งที่แคร่ไม้หน้าบ้านจำเลย แล้วจำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายที่ 1 ด้วยการใช้นิ้ว มือแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 แล้วชักเข้าชักออกหลายครั้ง จำเลย กระทำเช่นนี้กับผู้เสียหายที่ 1 รวม 2 วัน วันละ 1 ครั้ง คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดฐานพราก เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น รวม 2 กระหน ด้วยหรือไม่ เห็นว่า บทบัญญัติความผิดมาตรานี้มุ่งคุ้มครองอำนาจปกครอง

ดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มิให้ถูกผู้ใดล่วงละเมิดได้ ข้อสาระสำคัญจึงอยู่ที่ว่า
ขณะมีการกระทำความผิด เด็กนั้นอยู่ในความปกครองดูแลของผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่
หากปรากฏว่าเด็กอยู่ในอำนาจปกครองดูแลไม่ว่าเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว ผู้
ใดก็ไม่อาจมารบกวนหรือทำให้อำนาจปกครองของบุคคลนั้นต้องถูกกระทบกระเทือน
โดยปราศจากความรู้เห็นยินยอมของบุคคลดังกล่าวได้ ฉะนั้น เมื่อได้ความว่าขณะ
เกิดเหตุผู้เสียหายที่ 1 อยู่ในอำนาจปกครองดูแลของนาง ห. อำนาจปกครองที่มีต่อผู้
เสียหายที่ 1 ย่อมคุ้มครองโดยกฎหมายมิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้ ผู้เสียหายที่ 1
เพียงแต่เดินผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่ 1 จะไปตามนาย ต. กลับมารับประทานอาหาร
ที่บ้าน เหตุที่แะไปหาจำเลยเพราะจำเลยเรียกผู้เสียหายที่ 1 ให้เข้าไปหาที่แคร่หน้า
บ้านจำเลยแล้วล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายที่ 1 จึงถือได้ว่าเป็นการพรากเด็กออก
จากอำนาจปกครองที่มีอยู่เหนือผู้เสียหายที่ 1 ชั่วต้น เป็นเหตุให้อำนาจปกครองถูก
กระทบกระเทือนแล้ว แม้โจทก์บรรยายฟ้องอ้างว่าผู้เสียหายที่ 1 อยู่ในความปกครอง
ดูแลของผู้เสียหายที่ 2 มิใช่ นาง ห. ตามที่พิจารณาได้ความก็ตาม แต่เป็นเพราะต่อมา
นาง ห. ถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายที่ 1 จึงมาอยู่ในความปกครองดูแลของผู้เสียหาย
ที่ 2 ในภายหลัง ดังที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายที่ 2 เป็นผู้ปกครองดูแลผู้เสีย
หายที่ 1 อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลผู้ปกครองดูแลผู้เยาว์ในคดีนี้จะ
คลาดเคลื่อนไปก็ตาม ข้อแตกต่างดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นข้อสำคัญอันกระทบต่อสาระอัน
เป็นเนื้อหาขององค์ประกอบความผิดมาตรานี้ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย อีกทั้ง
จำเลยเองมีบ้านอยู่ใกล้กันกับผู้เสียหายที่ 1 ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าผู้เสียหายที่ 1 อยู่
ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลใดในช่วงเวลาใด ไม่มีเหตุที่จะหลงต่อสู่จากการ
บรรยายฟ้องของโจทก์ถึงผู้ปกครองดูแลที่แตกต่างไปจากทางพิจารณาที่ได้ความ
ศาลขอจะลงโทษจำเลยไปตามข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได้ความดังกล่าวนั้นได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง การที่ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 พินิจพิเคราะห์ข้อหาในข้อหานี้มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง คดีนี้แม้การที่จำเลยใช้นิ้วมือแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ไม่เป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) อีกต่อไป เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 โดยเพิ่ม (18) ของมาตรา 1 คำว่า "กระทำชำเรา" กำหนดบทนิยามของการกระทำชำเราเสียใหม่ เป็นเหตุให้การใช้สิ่งอื่นใดที่มีใช้อวัยวะเพศกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ไม่ถือเป็นการกระทำชำเราอีกต่อไปดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยก็ตาม แต่ลักษณะของการกระทำดังกล่าว กฎหมายที่แก้ไขก็หาได้ยกเลิกว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเสียทีเดียวหากได้นำไปบัญญัติไว้เป็นบทหนักของความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามมาตรา 279 วรรคห้า ซึ่งมีการแก้ไขคราวเดียวกันว่า ถ้าการกระทำอนาจารเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมีใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็ก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิตกรณีจึงมิใช่เรื่องที่กฎหมายยกเลิกมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดอีกต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง ฉะนั้น การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหายที่ 1 จึงต้องปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ดังกล่าว โดยถือว่ามิใช่ลักษณะของการกระทำผิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติตั้งหมายเหตุทำพระราชบัญญัติถึงเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายซึ่งเป็นคุณแก่จำเลย หาใช่ปรับบทความผิดตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (เดิม) ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยและพิพากษายืนในส่วนนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งไม่ถูกต้อง ปัญหาการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้โจทก์ไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งเห็นได้ว่า กำหนดระวางโทษไว้เท่ากับที่กำหนดไว้ในมาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) การลงโทษจำเลยจึงต้องปรับบทลงโทษตาม มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) เพราะกำหนดระวางโทษใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 โดยถือว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ที่ต้องลงโทษตามมาตรา 277 (เดิม) เป็น กฎหมายบทที่กำหนดโทษไว้หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ด้วย ฉะนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ลงโทษฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบาย หลอกลวงโดยอ้างว่าเป็นบทหนัก จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขแต่ไม่อาจ ลงโทษจำคุกจำเลยฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งมีใช่วัยวะเพศล่วงล้ำวัยวะเพศของเด็กได้เกินกว่ากระทรวงละ 2 ปี เพราะจะ เป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยโดยที่โจทก์มิได้ฎีกา อันต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้ไขเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม, 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) ด้วย โดยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร จำคุกกระทรวงละ 5 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปี ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้วิธีอื่นซึ่งมิใช่วัยวะเพศล่วงล้ำวัยวะเพศของเด็ก ฐานพา เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และฐานพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวง เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐาน กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยใช้วิธีอื่นซึ่งมิใช่วัยวะเพศล่วง

ล้าอวัยวะเพศของเติ็กตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า โดยปรับบท
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) จำคุกกระทงละ 2
ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 14 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ 3

(ธนสิทธิ์ นิลกำแหง-สิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล-ธนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายยุทธนา คุ่มมี

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายไพศาล โกสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ